

1500782-26.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... admitiu que realmente praticava o tráfico na ocasião, porque passava necessidade financeira e não conseguiu arrumar emprego após deixar a Fundação Casa. Ficou internado na Fundação Casa por cerca de 6 meses, pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas (v. mídia).

Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Jardim América, Sertãozinho - SP -
cep 14160-260

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500782-26.2022.8.26.0530

Controle: 2022/000692

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2083774/2022 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES

Aos 20 dias do mês de julho de 2022, às 16:10 horas, foi aberta a audiência, nos autos da ação supra referida realizada por meio virtual semipresencial, através do aplicativo Teams. Aberta com as formalidades legais, foram apregoadas as partes que participaram da videoconferência. A gravação será disponibilizada no sistema informatizado SAJ-PG5, conforme Comunicado Conjunto 1350/2020. Pelas partes foi manifestada concordância para que as gravações fossem feitas de forma individualizada, em arquivos separados de acordo com o número de testemunhas, visando facilitar futuros acessos. Sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. ANGEL TOMAS CASTROVIEJO, comigo Escrevente abaixo assinado, COMPARECERAM de forma virtual através do aplicativo TEAMS o Promotor de Justiça, Dr. EDUARDO LUIZ MICHELAN CAMPANA; o réu Marcos Vinícius de Souza Rodrigues, sua Defensora nomeada, Dra. PAULA RAFAELA GOUVÊA (OAB/SP 428305); COMPARECERAM presencialmente ao prédio do fórum desta comarca: as testemunhas arroladas pela acusação Policiais Militares Edgar Rogério Arantes e Arthur Henrique de Carvalho Pires. À defesa foi dada a oportunidade de entrevista prévia e reservada com o acusado antes de seu interrogatório, em sala virtual. Iniciados os trabalhos, o MM. Juiz inquiriu as testemunhas arroladas pela acusação Policiais Militares Edgar Rogério Arantes e Arthur Henrique de Carvalho Pires, qualificadas em videoconferência; pelo método audiovisual (artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e item 77, Capítulo II, NGSCJ), conforme gravação no sistema SAJ. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e

vídeo através do aplicativo TEAMS, conforme acima citado. A seguir o MM. Juiz interrogou o réu Marcos Vinícius de Souza Rodrigues, pelo método audiovisual (artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e item 77, Capítulo II, NGSCJ), conforme gravação no sistema SAJ. E, não havendo outras provas a serem produzidas, o MM. Juiz declarou encerrada a instrução processual e passou aos debates orais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e à Dra. Defensora, a explanação de cada um também foi captada em meio audiovisual através do aplicativo TEAMS e registrada no sistema SAJ. As partes dispensaram cópia em mídia CD (artigo 405, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal). A seguir pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA:

"Vistos.

MARCOS VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 27 de março de 2022, por volta das 12h15min, na rua Guilherme Paschoal Zamprônio nº 1021, Conjunto Habitacional Anélio Celline, nesta cidade e comarca de Sertãozinho, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 22 (vinte e dois) papелotes de Maconha pesando 61,09g (sessenta e um gramas e nove centigramas) e 56 (cinquenta e seis) cápsulas tipo eppendorf de Cocaína pesando 72,6g (setenta e dois gramas e seis decigramas), substâncias entorpecentes capazes de determinar a dependência física e psíquica. Segundo a denúncia, na data dos fatos policiais militares realizavam um patrulhamento rotineiro no bairro supracitado, conhecido pelo intenso tráfico ilícito de entorpecentes, quando notaram que o acusado empreendeu fuga assim que percebeu a aproximação da viatura. Ele foi perseguido e acabou sendo detido em um dos blocos do Residencial Aragão. Durante a revista pessoal, foi encontrada, em poder de Marcos, uma sacola plástica contendo 22 (vinte e duas) porções de Maconha e 56 (cinquenta e seis) cápsulas tipo eppendorf de Cocaína, além de R\$ 113,00 (cento e treze reais) em dinheiro. O acusado foi preso em flagrante delito e admitiu a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, dizendo que havia deixado a Fundação Casa há pouco tempo e vendia drogas porque estava desempregado. A denúncia foi recebida em 27/07/2022 (fls. 67/69), o réu foi citado (fls. 73) e apresentou defesa prévia (fls. 77/78).

Durante a instrução foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu interrogado ao final.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da cauda de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como das atenuantes da menoridade relativa e a confissão espontânea, fixando-se regime aberto.

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 11), pelas imagens fotográficas (fls. 12 e 13), pelos exames químicos-toxicológicos (fls. 51/53 e 54/56), conclusivos por se tratar de Maconha e Cocaína, respectivamente, e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também é indubitável.

Os policiais militares Edgar e Arthur, tanto na fase policial quanto em Juízo, disseram que efetuavam patrulhamento de rotina pela via local dos fatos, conhecido pelo comércio de entorpecentes, quando o réu, que estava parado num ponto de ônibus, e ao avistar a viatura policial, saiu correndo, sendo acompanhado e detido dentro de um dos blocos do residencial Aragão. Em revista pessoal, foi encontrada uma sacola plástica, que em seu interior havia os entorpecentes e o dinheiro apreendidos. Indagaram o réu e ele afirmou que está desempregado, que saiu há pouco tempo da Fundação Casa e estava vendendo a droga para conseguir dinheiro. Em Juízo, os policiais ressaltaram que não conheciam o réu anteriormente, e que dentre as pessoas que estavam no ponto de ônibus apenas o réu empreendeu fuga com a

aproximação da viatura (fls. 05, 06 e mídia).

O réu, interrogado na fase policial, confessou que estava vendendo as drogas apreendidas, e assim o fazia pois estava desempregado (fls. 07).

Em Juízo, admitiu que realmente praticava o tráfico na ocasião, porque passava necessidade financeira e não conseguiu arrumar emprego após deixar a Fundação Casa. Ficou internado na Fundação Casa por cerca de 6 meses, pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas (v. mídia).

Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que o acusado era realmente o proprietário da droga apreendida, e que se destinaria a consumo de terceiros, ainda que não tenha sido flagrado negociando a venda do entorpecente com qualquer pessoa.

Os policiais militares narraram de forma uníssona que estavam em patrulhamento, pelo local dos fatos, local esse conhecidíssimo pelo tráfico de drogas, e que, com a aproximação da viatura, o réu empreendeu fuga, mas foi perseguido e detido.

Confirmaram também os policiais que, ao ser revistado, encontraram na posse do réu as drogas mencionadas no auto de exibição e apreensão (fls. 10) e ainda

evidenciadas pelas imagens fotográficas (fls. 12 e 13). Disseram ainda que o próprio réu confessou que as drogas a ele pertenciam e que as estava traficando.

Ademais, o próprio réu confessou que estava traficando os entorpecentes encontrados com ele, pois estava desempregado e precisava de dinheiro.

Assim, considerando que a significativa quantidade de droga encontrada - 22 (vinte e dois) papérolas de Maconha pesando 61,09g (sessenta e um gramas e nove centigramas) e 56 (cinquenta e seis) cápsulas tipo eppendorf de Cocaína pesando 72,6g (setenta e dois gramas e seis decigramas) - é muito superior ao que normalmente encontrada com meros usuários, bem como a forma em que estava acondicionada, em porções individuais próprias para comercialização, que o réu estava em local muito conhecido pela ocorrência do tráfico e ainda confessou a prática do delito, conclui-se que a droga realmente se destinava ao comércio ilícito.

Não prospera, porém, a tese apresentada pelo réu de que agiu acobertada por causa de inexigibilidade de conduta diversa ou estado de necessidade. A inexigibilidade de conduta diversa ou mesmo o estado de necessidade são matérias que devem ser comprovadas pela Defesa (CPP, art. 156) e não foram demonstrados nos autos, não bastando a mera alegação do réu de que estaria passando por necessidade financeira para justificar sua conduta ilícita.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, além de ser confesso, porém tais circunstâncias atenuantes não tem o condão de fazer com que a pena seja reduzida aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, reputo incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Tal benesse deve ser concedida apenas aos agentes primários, de bons antecedentes, e que não se dediquem a atividades criminosas e nem integrem organização criminosa.

Porém, no presente caso, o réu já foi internado na Fundação Casa pela prática de inúmeros atos infracionais equiparados ao tráfico (v. certidão de fls. 28/29), e conforme ele próprio admitiu quando interrogado em Juízo.

O réu ainda foi flagrado comercializando grande quantidade de droga, de espécies variadas, como já mencionado. Destaco ainda a natureza de alta potencialidade lesiva de uma das drogas encontradas com o réu (Cocaína).

O réu, ademais, foi encontrado em região onde a traficância é estruturada e se desenvolve de forma endêmica, indicando que claramente se incorporou à organização criminosa, ou, no mínimo, que tem se dedicado frequentemente à traficância, além de que o acusado não comprovou nos autos, com segurança, o exercício de qualquer

atividade remunerada lícita.

Por todos referidos motivos, o réu não pode ser considerado mero traficante eventual ou se sustentar que não se dedica a atividades criminosas.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena fixada.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Relativamente ao regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cumpre observar o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 97.256/RS.

Em referido julgado o Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a ordem pleiteada e decidiu pelo cabimento de pena alternativa, removendo o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, julgado inconstitucional nesta parte, assim como da expressão análoga "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Assim foi redigida a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do

art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convolação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113).

Seguindo a determinação do Colendo Supremo Tribunal, cuja decisão, por força da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, com fundamento no art. 52, X, da Constituição Federal, passou a ter efeito “erga omnes”, cumpre avaliar as condições objetivas e subjetivas para a fixação do regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Para tanto, o próprio Supremo Tribunal Federal observou neste julgado que cabe ao juiz sentenciante “o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”. Ponderou também que “a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal; as demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero”.

Assim sendo, analisando o caso concreto, além de a penalidade imposta impedir, reputo não socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, para reprovação e prevenção do crime, bem como conveniente e adequada a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao réu, nos termos do artigo 33, § 1º, “a” c.c. artigo 33, § 3.º, do Código Penal.

Inicialmente observo que o tráfico de drogas é de gravidade social elevada, notadamente em razão de suas sérias consequências, tão nefasto à saúde pública e à sociedade. Isso porque arrebatava vidas do seio familiar, causa danos à saúde pública, e afeta a psicologia de toda a sociedade. É o consumo de psicotrópicos que corrompe o indivíduo socialmente sã, aliciando-o para o cometimento de delitos contra o patrimônio, delitos domésticos, em evolução criminosa até culminar com crimes contra o bem constitucional vida, bem como responsável pela desestruturação de muitas famílias.

Não bastasse, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á em observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código e, especificamente em relação aos crimes previstos na Lei de Drogas, deve-se ter em conta ainda as regras previstas nos artigos 42 e 43 da Lei 11.343/06, que determinam sejam consideradas, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

A propósito, ressalto que o acusado estava na posse de significativa quantidade de droga, de variadas espécies, e já foi internado por significativo tempo na Fundação Casa pela prática de atos infracionais equiparados ao tráfico. Destaco ainda a natureza de alta potencialidade lesiva de uma das drogas encontradas com o réu (cocaína). Ademais, o réu não comprovou, de forma idônea, o exercício de atividade remunerada lícita, indicando que vivia desta prática ilícita, a merecer ser duramente apenado.

E também pelos mesmos motivos que justificaram a fixação do regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, ainda mais porque permaneceu preso durante todo o processo, para garantia da ordem pública, nada justificando a soltura após a condenação.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu

MARCOS VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06. Declaro a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido, porque não comprovada sua origem lícita, presumindo que fosse proveniente da atividade ilícita do tráfico.

Em face da condenação, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita."

Pelo Réu e sua Dra. Defensora foi dito que RECORREM da r. sentença. Pelo Promotor de Justiça foi dito que CONCORDA com a r. sentença. Por fim, pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso interposto pela defesa. Aguardo as razões. Após, ao Ministério Público para que apresente as contrarrazões. Apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça. EXPEÇA-SE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA URGENTE. Arbitro honorários advocatícios à Defensora nomeada Dra. Paula Rafaela Gouvêa (OAB/SP 428305) em 70% da tabela OAB/Defensoria, EXPEÇA-SE certidão. Oficie-se o necessário. Comunique-se. Publicada em audiência, saem intimados os presentes. Nada mais." Eu, _____, Marco Antônio Veiga, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.